

0001480-18.2015.8.26.0283

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Favorecimento real

Magistrado: Leonardo Christiano Melo

Comarca: Itirapina

Foro: Foro de Itirapina

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 31/03/2022

... o entendimento jurisprudencial:

"PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. NÃO ACOLHIMENTO. CRIME DE FAVORECIMENTO REAL IMPRÓPRIO. ART. 349-A DO CP. INGRESSAR COM CHIP DE APARELHO DE TELEFONIA MÓVEL EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL. TIPICIDADE DA CONDUTA. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE MULTA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. EXCLUSÃO. MAUS ANTECEDENTES. NÃO OBSERVÂNCIA DO PERÍODO ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Itirapina

Foro de Itirapina

Vara Única

Rua 01, nº 180, Itirapina - SP - cep 13530-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

0001480-18.2015.8.26.0283 - lauda

SENTENÇA

Processo Físico nº:

0001480-18.2015.8.26.0283

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Favorecimento real

Autor:

Justiça Pública

Réu:

WELLINGTON DE OLIVEIRA FELISMINO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Leonardo Christiano Melo

I- Relatório

Trata-se de ação penal proposta pelo Ministério Público do Estado de São Paulo contra WELLINGTON DE OLIVEIRA FELISMINO pela suposta prática do crime previsto no art. 349-A do Código Penal. Segundo consta, no dia 03 de março de 2015, por volta das 17h05min, na Penitenciária I de Itirapina, situada na Avenida Otoniel Augusto Rodrigues, neste Município e Comarca de Itirapina, promoveu a entrada de uma bateria de aparelho celular, marca Samsung, sem autorização legal, no referido estabelecimento prisional (conforme laudo pericial de fls. 32/33).

A denúncia foi recebida em 13/07/2016 (fl. 120), o acusado foi citado por edital (fl. 124) e apresentou resposta à acusação por meio de defensor nomeado (fls. 132/136).

Na sequência o processo foi suspenso, conforme art. 366 do Código de Processo Penal (fl. 137).

Em instrução foram ouvidas as testemunhas arroladas, à título de produção antecipada de provas (fls. 149/152).

Posteriormente o acusado foi localizado e citado pessoalmente (fl. 178), ocasionando a revogação da suspensão condicional (fl. 185).

Entretanto, verificou-se que o acusado mudou de endereço sem comunicar o juízo (fl. 216), sendo decretada a sua revelia (fl. 221).

Em debates, o Ministério Público requereu a condenação do acusado, nos termos da

denúncia (fls. 223/225).

A Defesa, por sua vez, pugnou pela absolvição pela atipicidade da conduta.

Subsidiariamente, requereu o reconhecimento da figura tentada, com a devida redução da pena (fls. 229/231).

É o relatório. Fundamento e DECIDO.

II- Fundamentação

A pretensão punitiva estatal é procedente.

A materialidade foi demonstrada pelo boletim de ocorrência (fls. 03/04), auto de exibição e apreensão (fl. 07), laudo pericial (fls. 32/35) e pela prova oral produzida.

A autoria também é certa.

Embora em juízo tenha sido decretada a revelia do acusado, na sindicância administrativa este confessou a prática do crime, aduzindo que adentrou a portaria da unidade prisional e ao chegar no portão da gaiola do semiaberto, antes de passar pela revista corporal, avistou um pequeno objeto embrulhado com plástico, próximo aos tambores de lixo, e o pegou por curiosidade. Em seguida, ao constatar que era uma bateria de celular, ficou confuso e num momento de fraqueza resolveu entrar com a bateria para vendê-la dentro do semiaberto, a fim de ajudar sua família, que passa por dificuldades financeiras. Declarou que tem oito filhos e sua mulher está grávida de gêmeos (fl. 22vº).

O depoimento do acusado está em total consonância com as declarações das testemunhas, Agentes de Segurança Penitenciária:

A testemunha Anivaldo de Andrade, agente penitenciário, declarou que estava trabalhando no setor de scanner corporal, momento em que chegou Wellington, que retornava do trabalho externo; Ao realizar os procedimentos de praxe, detectou uma bateria de celular em sua boca. Explicou que o acusado passou pelo detector de metais e, com seu acionamento, realizou revista corporal no acusado. Quando não localizou nada em suas vestes, pediu para que Wellington abrisse a boca, momento em que encontrou a bateria.

A testemunha Valdir Dorta, agente penitenciário, corroborou os dizeres de seu colega de trabalho, acrescentando que o acusado trabalhava em São Carlos e, à tarde, quando retornou a unidade prisional, ocultava uma bateria de celular na boca. Explicou que o detector de metal foi acionado quando o detento passou pelo aparelho.

Conforme jurisprudência, o depoimento de agentes de segurança, especialmente quando prestado sob o crivo do contraditório, reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não cabendo sua desqualificação pelo só fato de emanar de agente estatal incumbido, por dever de ofício, da repressão criminosa (STF HC n. 73.518/SP, Rel. Min. Celso de Mello, j. 26.03.96).

Nessa linha também: "[...] 3. Não há como afastar a credibilidade dos depoimentos de policiais prestados em juízo, que, juntamente com outras provas submetidas ao contraditório e à ampla defesa, foram utilizados para corroborar o acervo fático-probatório e fundamentar a condenação. Precedentes." (REsp 1302515 /RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, 6ª Turma, j. 05/05/2016, DJe 17/05/2016)

Isto posto, sem olvidar as cautelas e limitações que revestem as provas produzidas durante o inquérito policial, observo que o depoimento do acusado na sindicância administrativa foi corroborado pelos depoimentos colhidos sob o manto do contraditório, formando um conjunto probatório coerente e idôneo, apto a ensejar a condenação do réu.

Advirto ser prescindível a realização de perícia sobre o aparelho. Isso porque o art. 349-A do Código Penal tipifica a conduta daquele que ingressa em estabelecimento prisional em poder de aparelho telefônico de comunicação móvel, de rádio ou similar, restando abrangidos, nesse último tópico, eventuais peças sobressalentes como baterias, antenas ou chips.

Assim, ainda que a bateria apreendida não fosse hábil para, por si só, efetuar ligações, ainda assim resta configurado o crime, eis que poderia substituir partes defeituosas de outros telefones, vulnerando o bem jurídico tutelado.

Acerca da questão, o Des. Fernando Torres Garcia, citando André Estefam, asseverou que "não se trata de analogia 'in malam partem' (vedada), mas de interpretação

extensiva (permitida), já que a normal não é ampliada, nesse caso, para fora de seu âmbito, atingindo situação nela não prevista, mas estendida dentro do limite de seu próprio âmbito, porque se nota que o legislador disse menos do que queria ('lex dixit minus quam voluit'). A prevalecer solução diversa, a lei coibiria o ingresso do aparelho intacto, mas não puniria sua entrada fracionada, o que se mostra de todo absurdo" (Processo: 0000473-75.2011.8.26.0268; Relator: Des. Fernando Torres Garcia; Comarca: Itapeceira da Serra; Órgão julgador: 14ª Câmara de Direito Criminal; Data do julgamento: 27/06/2013).

O c. STJ, ao interpretar a expressão "aparelho telefônico, de rádio ou similar", para fins de caracterização de falta grave na execução da pena (art. 50, VII, da LEP), pacificou o entendimento de que nela estaria incluída qualquer componente essencial ao funcionamento do celular, uma vez que "a ratio essendi da norma é proibir a comunicação entre os presos ou destes com o meio externo" e, entender em sentido contrário, permitindo a entrada fracionada do aparelho telefônico, seria uma burla à previsão legal (HC 230.659/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 05/11/2013, DJe 19/11/2013).

Nessa mesma linha de raciocínio, digno de menção o seguinte julgado da Corte Superior: "[...] 3. É cediço que o propósito primordial da alteração legislativa promovida pela Lei n.º 11.466/2007 foi conter a comunicação entre os presos e o ambiente externo, evitando-se, assim, a deletéria perpetuação da atividade delitativa, notadamente se considerada a proliferação da criminalidade organizada até mesmo no interior dos cárceres. Assim, há de se ter por falta grave não só a posse de aparelho de telefonia em si, mas também de qualquer outro componente imprescindível para o seu funcionamento. Conclusão diversa permitiria o fracionamento do aparelho entre cúmplices apenas com o propósito de afastar a aplicação da lei e de escapar das sanções nela previstas. Flagrante ilegalidade inexistente." (HC 228.044/ SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, julgado em 20/09/2012, DJe 26/09/2012).

Nesse sentido o entendimento jurisprudencial:

"PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. NÃO ACOLHIMENTO. CRIME DE FAVORECIMENTO REAL IMPRÓPRIO. ART. 349-A DO CP. INGRESSAR COM CHIP DE APARELHO DE TELEFONIA MÓVEL EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL. TIPICIDADE DA CONDUTA. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE MULTA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. EXCLUSÃO. MAUS ANTECEDENTES. NÃO OBSERVÂNCIA DO PERÍODO DEPURADOR. QUANTIDADE DE AUMENTO. DISCRICIONARIEDADE DO MAGISTRADO. PARCIAL PROVIMENTO. 1. Não há de se falar em desclassificação diante de vasto conjunto que comprova a traficância, em especial a prisão em flagrante delito, palavra dos agentes penitenciários e quantidade da droga apreendida. 2. A palavra dos policiais é prova idônea a embasar o decreto condenatório, especialmente quando em harmonia com as demais provas dos autos. 3. O período depurador de 5 (cinco) anos, previsto no artigo 64, inciso I, do Código Penal, apenas afasta a configuração da agravante da reincidência, de forma que as condenações anteriores ao referido período podem ser utilizadas na fixação da pena-base, a título de Maus antecedentes. 4. A lei penal não estabelece fração específica de aumento ou diminuição da pena-base. Esta Corte tem adotado o coeficiente imaginário de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo de tempo existente entre as penas mínima e máxima cominadas ao tipo penal, sem retirar do julgador certa dose de discricionariedade sobre o montante aplicado, desde que exercida com fundamentação idônea e observada a proporcionalidade, o que se observou nestes autos. Portanto, inviável o pleito da Defesa de aplicação da fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima prevista no tipo penal. 5. A aplicação da agravante da reincidência na segunda fase e a sua utilização na terceira fase, para afastar o tráfico privilegiado, não atraem o odioso bis in idem, pois se relacionam à consequências diversas do mesmo instituto. 6. O réu ingressou no estabelecimento penal com chip de aparelho de telefonia móvel, o que configura o crime do art. 319-A do Código Penal, haja vista tratar-se o chip de componente essencial ao funcionamento do celular. 7. Não prevendo o preceito secundário do tipo penal a possibilidade de imposição de pena de multa, revela-se imprescindível o afastamento da condenação do réu ao pagamento desta espécie de sanção penal. 8. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJ-DF 07239359220198070001 DF 0723935-

92.2019.8.07.0001, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, Data de Julgamento: 20/08/2020, 3ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no PJe : 28/08/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Configurado está, portanto, o crime do art. 349-A do Código Penal, haja vista tratar-se a bateria de componente essencial ao funcionamento do celular. Assim, comprovada a autoria e materialidade da infração penal, não havendo qualquer causa excludente, de rigor a condenação do réu. Passo a dosar a pena.

De plano, destaco que "(...) A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. (...)." (STF, RHC 105921, Relator(a) p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 29/03/2016). No mesmo sentido: STJ, HC 333.860/MA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2015, DJe 01/02/2016.

Na PRIMEIRA FASE: Analisadas as diretrizes do artigo 59 do Código Penal a culpabilidade é normal. O acusado possui maus antecedentes (fl. 41 - Proc. nº 62346/2004). Não há dados para mensurar sua conduta social e personalidade.. O motivo do delito seria ínsito à natureza da infração. As circunstâncias do delito não destoam daquelas em que ocorrem crimes desta natureza. As consequências não foram graves. Atentando às diretrizes do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena base em 1/6 acima do mínimo legal, resultando-se em 3 meses e 15 dias de detenção. Na SEGUNDA FASE, presente a agravante da reincidência (fl. 41 - Proc. nº 6742630/2010) a pena deve ser agravada em mais 1/6, atingindo 4 meses e 2 dias de detenção.

Na TERCEIRA FASE, não há causas de aumento ou de diminuição. Torno definitiva a pena de 4 (quatro) meses e 2 (dois) dias de detenção.

Regime de Cumprimento da Pena

Em atenção aos parâmetros do art. 33 do Código Penal, estabeleço o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena, em razão de sua reincidência, nos termos do que estabelece a Súmula nº 269 do STJ.

Substituição da Pena Privativa de Liberdade

Deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, pois o acusado é reincidente (art. 44, II, do Código Penal). Pelo mesmo motivo, inviável a suspensão condicional da pena (art. 77, I, do Código Penal).

III - Dispositivo

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal para CONDENAR WELLINGTON DE OLIVEIRA FELISMINO pela prática do crime previsto no art. 349-A do Código Penal, à pena privativa de liberdade de 4 (quatro) meses e 2 (dois) dias de detenção, em regime inicial semiaberto.

Direito de Recorrer em Liberdade

Tendo em vista a pena aplicada, o réu poderá recorrer em liberdade desta decisão, pois respondeu ao processo nesta condição e estão ausentes os fundamentos da prisão preventiva. Além disso, deve ser preservado o princípio da homogeneidade entre a medida processual de prisão cautelar e a pena imposta ao réu.

Despesas Processuais (arts. 1.092/1.098 da NSCGJ T. I)

Condeno o(s) ré(u)(s) ao pagamento das despesas processuais; contudo, sua cobrança poderá ser sobrestada, desde que comprovado seu estado de pobreza em execução.

Honorários Advocatícios

Havendo Defensor nomeado pelo Convênio OAB/DP, fixo honorários ao(s) procurador(es) nomeado(s) nestes autos em 100% do valor da Tabela de Honorários do Convênio OAB/DP. Em caso de recurso de quaisquer das partes, expeça-se certidão (i) de 70% (setenta por cento) do valor da Tabela de Honorários do Convênio OAB/DP antes da remessa dos autos ao Egrégio Tribunal de Justiça; e (ii) de 30% (trinta por cento) do valor da Tabela de Honorários do Convênio OAB/Defensoria Pública, após o trânsito em julgado. Não havendo recurso de nenhuma das partes, expeça-se certidão após o trânsito em julgado.

Fiança Eventualmente Recolhida

Quanto à eventual valor recolhido a título de fiança, destaco, desde logo, que nos termos do art. 347 do Código de Processo Penal "(...) o saldo [da fiança] será

entregue a quem houver prestado a fiança, depois de deduzidos os encargos a que o réu estiver obrigado." (destaque adicionado). Na mesma linha, "(...) a fiança teria a finalidade de garantir o pagamento das custas e também da multa (se for aplicada). (...)." (NUCCI, Guilherme de Souza. Tribunal do júri 6. ed. rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro : Forense, 2015).

Além disso, a fiança pode inclusive ser utilizada para quitação da pena restritiva de direitos de prestação pecuniária (STJ, RHC 68.142/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 17/03/2016, DJe 30/03/2016).

Portanto, após as deduções, se não reivindicado o valor restante de fiança recolhida, no prazo de 10 (dez) dias em seguida ao trânsito em julgado definitivo, determino sua perda em favor do Tesouro Nacional, com base no art. 483 das Normas de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça T I.

Disposições Finais

Oportunamente, após o trânsito em julgado: I) lance-se o nome do(s) réu(s) no rol dos culpados; II) em cumprimento ao art. 72, § 2º, do Código Eleitoral, oficie-se o Colendo Tribunal Regional Eleitoral da circunscrição de residência do(s) condenado(s), dando-lhe ciência da condenação, para cumprimento do inciso III do art. 15 da Constituição Federal ; III) oficie-se ao Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton Daunt (IIRGD) dando-lhe conhecimento ao resultado deste julgamento; IV) expeça-se guia de execução (ou de recolhimento), provisória ou definitiva, conforme o caso, para o devido encaminhamento do(s) condenado(s) ao estabelecimento prisional estabelecido nesta sentença; V) proceda-se o recolhimento do valor atribuído a título de pena pecuniária, em conformidade com o disposto pelo art. 686, do CPP.

P.I.C.

Itirapina, 24 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA